

1502331-53.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTOS

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502331-53.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502331-53.2022.8.26.0536 - Controle n.º 574/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNILSON CRUZ DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

EDNILSON CRUZ DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 4 de julho de 2022, por volta de 3h38min, na Avenida Marquês de São Vicente n.º 156, bairro Encruzilhada, neste município e comarca, mediante rompimento de obstáculo e utilizando desforço físico, subtraiu, para si, um cano de alumínio, medindo dois metros de comprimento e um portão de alumínio, avaliados em R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Diz a denúncia que, via COPOM, policiais militares foram informados sobre a ocorrência de um furto no local. De posse das características e vestimentas do furtador, saíram em patrulhamento a fim de localizá-lo.

Ao chegarem à Rua Gaspar Ricardo - caminho conhecido por ser trajeto de furtadores de peças de alumínio - os policiais encontraram o réu que estava na posse da barra de alumínio e do mencionado portão. Durante a abordagem, o acusado confessou informalmente a prática delitiva.

Por fim, diz a petição inicial que a res furtiva foi restituída à vítima (pp. 48/49).

Recebida a denúncia (pp. 50/51), foi o réu citado pessoalmente (p. 89). A Defesa

ofereceu a resposta de p. 92, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 94/95).

Na instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, procedendo-se ao interrogatório. As partes requereram e tiveram homologada a desistência do depoimento da testemunha Henrique Emanuel Ferreira da Silva, apesar de conectada para participar do ato (pp. 130/131).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a absolvição, sustentando que há dúvida sobre a autoria do fato delitivo (gravação audiovisual – pp. 130/131).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, reiterou o pedido de absolvição feito pelo Ministério Público, asseverando não existir prova suficiente para a condenação. Suscitou a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.940.726, julgado pela Quinta Turma, segundo o qual, em regra, quando o Ministério Público pede a absolvição, esse pedido deve ser acolhido, em respeito à separação das funções de acusar e julgar (gravação audiovisual – pp. 130/131).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente em parte.

A materialidade do crime está satisfatoriamente demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de p. 11.

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, e ciente da acusação que lhe era dirigida, o acusado manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (p. 6).

Em juízo, ao ser interrogado, disse que já respondeu outros processos e cumpriu pena. Estava em liberdade há mais de cinco anos antes de ser preso em razão deste processo. Não conhece o policial ouvido em audiência, nem o outro policial arrolado como testemunha, afirmando que não foram eles que o prenderam. Disse que estava andando pela Avenida Francisco Glicério e, como estão ocorrendo muitas reformas na região, passou por uma caçamba de entulho com pedaços de ferro e de alumínio, dentre os quais um pedaço de portão. O portão estava inteiro ali e estava amassado. Então, pegou o portão e o cano dessa caçamba. Coletou os bens por volta de 1h da madrugada. Afirmou que não retirou o portão do local de instalação no imóvel referido na denúncia. Não sabe por que motivo o acusam da prática dessa subtração. Tem 34 anos de idade. Exercia o ofício de prensista, mas, à época dos fatos, estava em situação de rua e trabalhava com reciclagem. Apesar de ter família em São Vicente, não vive com eles uma vez que não se relaciona bem com sua mãe. Tem uma companheira e um filho de 15 anos de idade, fruto de relação com outra mulher. Estudou até a 8ª série, mas abandonou o colégio para trabalhar (gravação audiovisual – pp. 130/131).

E, ao que se vê do processado, ao contrário do que sustentaram as partes, é certo que a prova reunida no contraditório dá sustento à condenação, revelando-se firme, segura e coerente.

R.S.M. disse que estava dormindo e, durante a madrugada, escutou barulho de alumínio, provavelmente vindo de baixo. Abriu a janela e viu que havia um indivíduo forçando a grade do portão para retirá-la. Rapidamente pegou o celular, desceu, entrou em seu veículo, ligou para a polícia relatando o ocorrido e tentou ir atrás do furtador, que dali levou os bens retirados do local de instalação. Relatou que, como estava de carro, não conseguiu fazer a perseguição porque precisaria entrar em vias pela contramão em certas ruas. Então, retornou à sua residência e, em seguida, recebeu uma ligação da Polícia informando que haviam encontrado o acusado com a grade que ele havia descrito. Declarou que reconheceu o réu na Delegacia como sendo a pessoa que cometeu o delito, uma vez que o viu quando ainda estava em seu apartamento. No dia seguinte, retirou a grade que lhe foi restituída e a reinstalou no imóvel. Em audiência por videoconferência, ao observar o acusado, não foi capaz de afirmar sem sombra de dúvida que seria ele o autor do furto, pois o réu estava com o cabelo cortado, o que dificultou a identificação. No entanto, afirmou que tinha certeza que a pessoa que foi presa com o portão e logo depois apresentada no

Distrito Policial era o autor do furto aqui apurado. Declarou ter visto o réu terminando de arrancar a grade e sair andando rapidamente com ela. Não viu se o acusado usou apenas as mãos para quebrar os rebites da grade. Disse que o ruído mais alto, que o acordou, certamente foi o da retirada do portão da instalação, pois o portão foi puxado pelo réu (gravação audiovisual – pp. 130/131). Danilo de Souza, policial militar, disse que estavam parados perto da estação Nossa Senhora de Lourdes e receberam a informação, via COPOM, de que havia acabado de ocorrer o furto de um portão nas proximidades. Alguns minutos depois, um indivíduo com as características informadas passou levando um portão nas costas. Ao abordarem o acusado, ele afirmou que pegou o portão em outro lugar. Disse que levaram o réu ao Distrito Policial e, lá, o síndico do prédio reconheceu o acusado como o autor do furto. O síndico também reconheceu a res furtiva. Em audiência por videoconferência, ao observar o acusado, não foi capaz de afirmar com certeza que ele era o indivíduo detido no dia dos fatos, pois, àquela época, o réu estava com barba e cabelo compridos. Afirmou, por fim, que a pessoa detida com o portão furtado foi a mesma pessoa apresentada à autoridade policial. Não conhecia o réu antes dos fatos (gravação audiovisual pp. 130/131). Vê-se, assim, que ao contrário do que sustentaram a Acusação e Defesa, a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório, não sendo possível declarar a absolvição.

Sob o crivo do contraditório, o ofendido declarou que foi acordado com o barulho causado por alguém que forçou o portão do imóvel, para assim arrancar uma das grades ali existentes. De sua janela pôde ver, com clareza, o acusado retirando o portão e fugindo dali com o bem subtraído.

O representante da vítima narrou que ligou para Polícia Militar para informar a ocorrência do crime e ainda tentou perseguir o autor do crime, mas sem êxito, pois não poderia ingressar em vias de contramão. Explicou, ainda, que voltou para casa e, pouco depois, recebeu ligação informando a detenção do réu e a localização do bem subtraído.

Afirmou, em audiência, que, ao comparecer no Distrito Policial, reconheceu sem sombra de dúvida a pessoa detida como sendo a mesma que subtraiu o portão. Olhou a pessoa de seu apartamento, de cima para baixo, e por isso a reconheceu na data da prisão. Reconheceu também o portão apreendido como sendo o que foi subtraído do imóvel naquela noite.

Em situações como a aqui narrada, a palavra da vítima é de essencial importância, principalmente quando revestida de segurança e sinceridade, como aqui se verificou. É certo que, pelo coerente relato do ofendido, comprovado está que o réu é autor do furto narrado na denúncia, não se evidenciando qualquer intenção de prejudicar o acusado, pessoa que sequer conhecia.

Da lição de Mirabete se extrai que "...como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas (...). São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo...". (Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 1996, pp. 288/9).

E, como já se decidiu:

"... Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes..." (TJSP; Apelação Criminal 0031860-73.2017.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2020).

"... Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo..." (TJSP; Apelação Criminal 1500091-42.2018.8.26.0630; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2020).

O policial militar confirmou que a pessoa detida na rua enquanto carregava o portão subtraído foi aquele mesma apresentada à autoridade policial, tomando conhecimento que houve identificação do detido e também do bem subtraído.

Portanto, indiscutível está que a pessoa reconhecida pela vítima no Distrito Policial foi aquela encontrada com a res furtiva.

E, ainda que pareça redundante afirmar, é certo que a pessoa apresentada em audiência é a mesma detida naquela data e reconhecida pelo ofendido em sede policial, identificada como Ednilson Cruz de Moraes.

Desse modo, em que pese a dificuldade do ofendido e do policial militar identificar o réu na audiência, uma vez que este já não estava barbado e mostrando cabelos compridos, como estava na ocasião da prisão, não impede que se conclua que é ele o autor da subtração.

Com efeito, ao tempo da audiência de instrução, que ocorreu mais de quatro meses após os fatos, o réu se apresentava em boas condições de higiene pessoal, mostrando barba e cabelo aparados, além de adequadamente trajado, revelando a imagem mostrada ao ofendido e ao policial pessoa certamente diferente daquela que foi detida na ocasião do flagrante delito.

Mas, como se disse, não se tem dúvida que o réu foi preso em situação de flagrante e com ele estava a res furtiva, que assim foi recuperada e entregue à vítima.

Registre-se, ainda, que consoante entendimento predominante, a apreensão da res furtiva em poder do agente e logo após o fato gera presunção da responsabilidade dele na subtração, ocorrendo, assim, inversão do ônus da prova, competindo ao acusado trazer elementos capazes de comprovar que não foi o autor do delito.

Sobre o ônus probatório, colhe-se da lição de Marcos Vinicius Boschi e outros que "conforme iterativa jurisprudência, a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresenta é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado. A apreensão da res furtiva em poder de alguém, mormente logo após o delito, conforme a experiência ordinária, diz por si mesmo, revelando-se altamente incriminadora. A situação, diz a jurisprudência, assemelha-se a do alibi invocado e não demonstrado, fazendo com que o réu seja havido como confesso, ou, pelo menos, corra o risco de sê-lo, dès que os demais dados probatórios transformem em certeza a presunção gerada pela justificativa dúbia ou inverossímil." (Código de Processo Penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 169-170).

E, como já se decidiu:

"... Roubo e Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem..." (TJSP; Apelação Criminal 1501570-42.2019.8.26.0628; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021).

De outro lado, sabe-se que o réu não está obrigado a dizer a verdade: ao contrário, bem pode pretender alterar a verdade dos fatos, procurando afastar sua responsabilidade penal, justamente para não se prejudicar.

Nestes termos, inaceitável a versão que o réu ofertou, pois quis fazer crer que encontrou o portão abandonado em uma caçamba de lixo, em local próximo ao de sua detenção.

Evidente que não há como admitir essa versão, uma vez que bens compostos de alumínio vêm sendo alvo de inúmeros furtos nesta cidade, já que o metal valioso é rapidamente revendido a peso em ferros-velhos da região.

Também se sabe que pedaços de alumínio, justamente por serem tão facilmente vendidos e terem alto valor, não são costumeiramente descartados em caçambas de entulho.

Assim, é inacreditável que outrem houvesse empenhado tamanho esforço para realizar a remoção das peças de metal e se exposto ao risco de ser flagrado na prática do delito para simplesmente abandonar e largar os proveitos de sua empreitada criminoso à própria sorte.

Outrossim, e como se frisou, o ofendido foi acordado pelo alto ruído decorrente da ação criminosas, observando o autor do furto ainda no local do crime, reconhecendo horas depois na delegacia de polícia.

Além disso, o ofendido visualizou o cometimento do delito e reconheceu o acusado poucas horas após o ato.

Seria inacreditável imaginar que a vítima elaborasse fantasiosa história para acusar indevidamente o réu, pessoa que sequer conhecia, apontando-o como autor desse crime.

Despropositada, por absurda, essa situação.

Assim, não há como se desacreditar a palavra da vítima diante da inverossímil versão exculpatória oferecida pelo acusado.

Patente que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que o réu subtraiu o bem descrito na denúncia, apreendido em seu poder.

Outrossim, inequivocamente comprovado que se tratou de crime consumado, pois o acusado teve a posse mansa e pacífica da res.

Todavia, no tocante à caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, melhor sorte socorre o réu.

De acordo com o laudo de exame do local, "os vestígios aparentes de aspecto recente identificados e possivelmente relacionáveis com o objetivo da requisição, consistiam na ausência de ao menos cinquenta hastes que aparentemente deveriam estar presentes na porção superior das folhas da direita e central do portão e o desalinhamento destas além de amolgamento dos trilhos superiores e suas guias" (laudo de pp. 118/123), situação que permite concluir que a violência foi exercida diretamente contra o próprio portão.

Como se sabe, não se pode entender caracterizada a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a violência é exercida contra o próprio objeto furtado, uma vez que o tipo penal prevê a destruição ou o rompimento de barreira que impeça a subtração da res.

Neste sentido, lembra a doutrina que "não se aplica a qualificadora quando o agente atua contra a própria coisa" (Guilherme de Souza Nucci. Manual de Direito Penal. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 740).

Por outro lado, é de se reconhecer que caracterizada e comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena do repouso noturno, descrita na denúncia, uma vez que se tratava de alta madrugada (3h38min), período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res.

Deste modo, parece que a desclassificação é desfecho adequado à situação aqui apurada, uma vez que os fatos narrados na denúncia imputam ao acusado a prática de furto simples cometido durante o repouso noturno.

Assim, é caso de desclassificar a acusação contida na denúncia para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, dando-se nova e adequada definição jurídica à conduta do réu, tipificando-a no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal.

Por final, necessário destacar que, em que pese o argumento da Defesa, relativamente à impossibilidade de se prolatar juízo de condenação quando há pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, certo é que o entendimento esposado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, como reconhecido no acórdão referido, representa interpretação minoritária relativamente à disposição contida no artigo 385 do Código de Processo Penal.

Assim ensina Renato Brasileiro de Lima: "é dominante o entendimento no sentido de que é possível a prolação de uma sentença condenatória ainda que haja pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. É nesse sentido, aliás, a redação do art. 385 do CPP, que prevê que, nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição do acusado" (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 1653).

Com efeito, não há como impor ao juízo a obrigatoriedade de pronunciar desfecho absolutório tão somente porque há pedido de absolvição formulado pela Acusação

Pública, e isso porque a valoração da prova compete ao juízo, que assim declarará a procedência ou improcedência do pedido inicial.

Não bastasse, e em especial, a imposição dessa manifestação é de todo descabida porque não se tem nesta situação processual mera atividade homologatória da vontade ministerial.

Se assim fosse, sequer se demandaria prolação de sentença, já que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, ou pelo querelante em ação penal de iniciativa privada subsidiária, vincularia o juízo impondo a improcedência do pedido inicial.

Guardadas as proporções, uma vez que a manifestação ministerial é obrigatória nesta fase da persecução penal, ter-se-ia, às avessas, hipótese que se assemelha à perempção em ação penal de iniciativa privada exclusiva, verificada quando o querelante deixa de formular pedido de condenação em alegações finais (art. 60, inciso III, parte final, do Código de Processo Penal).

De outro lado, é de se frisar que não há violação ao princípio acusatório adotado no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, pois a estrutura acusatória exigida pela lei processual penal visa impedir a iniciativa do juiz na fase extrajudicial da persecução penal, como também veda essa iniciativa em substituição à atuação probatória do órgão da acusação, seja em ação penal pública, como também em ação penal de iniciativa privada.

O pedido de absolvição formulado pela Acusação, se vinculante fosse, esvaziaria a jurisdição, excluindo da apreciação do Poder Judiciário a demanda trazida a juízo, em afronta à expressa disposição constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).

Aliás, se essa vinculação fosse admitida, ter-se-ia transversa e indiscutível ofensa ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que rege a atuação do órgão oficial da Acusação, já que ao Ministério Público é vedado desistir da ação (artigo 42 do Código de Processo Penal), como também vedado é desistir do recurso que haja interposto (artigo 576 do mesmo Código).

Desta forma, não há como entender que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público dite e obrigue o desfecho absolutório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a manifestação do representante do Ministério Público não vincula o magistrado, e nem poderia fazê-lo, sob pena de indiscutível ofensa ao princípio acusatório, que exige a necessária separação de funções entre os órgãos julgador, acusador e defensor.

Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. 'Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado' (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual '[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação'. Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só,

nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro Luiz Fux, 'na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305', suspendeu, 'sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [...] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)'. 4. Ordem de habeas corpus denegada." (STJ, Habeas Corpus n.º 623.598/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/10/21).

"... O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de *judicium accusationis* do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu..." (STJ, AgRg no HC n.º 640.863/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021).

"... Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição..." (AgRg nos EDcl no HC n.º 537.251/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020).

Ademais, no mesmo sentido, extrai-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. 2. Nesse contexto, o parecer do Ministério Público, apresentado em segundo grau de jurisdição, não deve conduzir, necessariamente, à absolvição do paciente se a instância a quo entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a condenação. Precedente. 3. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar o édito condenatório. Logo, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento..." (STF, HC n.º 185.835 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020 - grifei).

Por fim, cabe ainda salientar que o entendimento constante do AREsp 1.940.726/RO não veda, de todo, a condenação quando há pedido de absolvição do Ministério Público, asseverando que "Ocorre que não há como cancelar uma condenação penal sem fundamentação adequada. Em verdade, para se contrapor a um pedido de absolvição da acusação, a sentença deve ser robustamente fundamentada, com a indicação de provas firmes e coerentes que apontem para direção diversa." (STJ, AgRg no AREsp n.º 1.940.726/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022), o que indiscutível aqui se verifica.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

O acusado é tecnicamente primário (pp. 17/20).

Todavia, ostenta duas condenações definitivas antigas pelos crimes de roubo majorado (autos n.º 0007897-33.2009.8.26.0562 - certidão de pp. 17/18) e de porte de arma e dano qualificado (autos n.º 0015414-16.2014.8.26.0562 - certidão de p. 18), condenações essas que ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, maculam sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal da acusada difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em

novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...”. (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Destaque-se, também, que o réu responde a duas ações penais pela prática de furto qualificado e de furto simples tentado (autos n.º 1502117-62.2022.8.26.0536 – certidão pp. 18/19, autos n.º 0004892-22.2016.8.26.0638 – certidão p. 19), mas tais apontamentos não serão aqui considerados, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, verificada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 155, do Código Penal, já que se tratou de subtração praticada durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstâncias que a modifiquem.

Ante o quantum de pena aplicada é de se entender que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente recomendável, e a substituição de uma delas por pena de multa não se mostra adequada à reprovação da conduta criminosa aqui apurada.

É necessário gizar que destaque negativo quanto aos maus antecedentes, por si só, não obsta a substituição, pois a análise conjunta de todas as outras circunstâncias do inciso II do artigo referido a indicam como suficiente à repressão e prevenção do crime.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços e prestação pecuniária, na forma do previsto nos artigos 45 e 46 do Código Penal. Fica o réu condenado ao cumprimento de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inseridos em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução.

Fica condenado, também, ao pagamento de prestação pecuniária estipulada em 1 (um) salário mínimo, a ser pago em dinheiro e em favor de entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução, na forma do previsto no parágrafo 1º do artigo 45 e 46 do Código Penal.

Por ser primário, em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direitos ora impostas, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar EDNILSON CRUZ DE MORAES, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à entidade assistencial, hospitalar, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inserido em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução; e prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo devido a entidade pública ou privada de destinação social, que também será indicada pelo Juízo da Execução, penas essas que, em caso de conversão, deverão ser cumpridas inicialmente em regime aberto, bem como 14 (catorze) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal.



Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual n.º 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

À vista da pena ora imposta, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 23 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA